

1523858-49.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... foi abordado por policiais, o que configura tráfico e não uso de drogas.

Assim, uma vez que o réu foi surpreendido tendo consigo substância entorpecente, não se pode falar em guarda para consumo próprio, com a consequente desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, mas sim em tráfico ilícito.

Certo é que, a só quantidade de droga, ainda que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1523858-49.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1523858-49.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO REZENDE ZORZO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Rodrigo Rezende Zorzo, qualificado nos autos na fl. 20, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº. 11.343/06, porque no dia 1º/outubro/2021, por volta das 16h, na Rua Porto de Dom Rodrigo, altura do número 391, Vila Lório, nesta comarca, agindo em concurso com o adolescente Kayk Mendes Paz, foi surpreendido trazendo consigo, para fins de tráfico, 11,4g de Benzoilmetilecgonina, mais conhecida como cocaína, em 15 invólucros, 15g de Tetraidrocanabinol, mais conhecido como maconha, em 5 invólucros, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta na denúncia que, na tarde dos fatos, policiais militares em patrulhamento

pela região, ponto de venda de drogas, avistaram o agente na companhia do menor em atitude suspeita, parados sem motivo numa escadaria; realizada a abordagem, em busca pessoal, foram localizadas na mão do indiciado as porções de cocaína e, no bolso da jaqueta do adolescente, as porções de maconha; indagado, o indiciado admitiu informalmente a traficância.

A denúncia (fls. 88/89) veio acompanhada do Inquérito Policial (fls. 01/77), sendo a peça acusatória recebida em 03/novembro/2021 (fls. 91/92). Após a necessária notificação/citação, o réu não apresentou Defesa Preliminar.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas (áudio - audiência virtual sistema Teams) e o denunciado interrogado ao final (áudio - audiência virtual sistema Teams).

Nas suas considerações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia, devendo a pena ser fixada acima do mínimo legal, devido a variedade de drogas e também por causa dos antecedentes quando era menor de idade; a pena também deverá ser exasperada em razão da causa de aumento de pena por envolver ao menor e, por fim, não há que se falar em aplicação do §4º, do artigo 33 da lei de drogas; a Defesa pugnou pela desclassificação para o crime de uso de drogas; em caso de condenação por tráfico, requereu a fixação da pena no mínimo legal, afastamento da causa de aumento relativa ao adolescente Kayk, fixando-se o regime aberto para início de cumprimento da pena.

O Laudo de Constatação Prévia encontra-se nas fls. 13/16; o de Exame Químico Toxicológico nas fls. 96/98 e o Auto de Exibição e Apreensão das substâncias entorpecentes está na fl. 10.

É o relatório.

Decido.

Ao término da instrução, verificou-se que os fatos narrados na exordial restaram comprovados, razão pela qual a ação deve ser julgada a favor da Justiça Pública. Interrogado em Juízo, o acusado Rodrigo Rezende Zorzo, 23 anos, negou a acusação; passou no ponto de venda e adquiriu drogas para uso próprio; pegou em quantidade suficiente para não ter que voltar lá por que é deficiente e só tem uma perna; Kayke apareceu em seguida e estavam juntos quando a polícia chegou e os prendeu; se diz usuário de maconha e cocaína há 2 anos; a cocaína era de Kayk e a maconha do interrogando (áudio sistema SAJ).

Na fase investigativa, alegou ser usuário de drogas (fls. 18).

Vejamos a prova do contraditório.

A testemunha Marllon Oliveira Mariano, policial militar, disse que, em patrulhamento de rotina por local conhecido pela venda de drogas, em um escadão, avistou duas pessoas que foram abordadas; encontrou com eles quantidade considerável de drogas (maconha e cocaína); ambos confessaram a traficância; também foi apreendido dinheiro que, salvo engano, estava com o menor; como o réu somente tem uma das pernas, essa situação o torna conhecido no meio policial (áudio sistema SAJ).

O depoente Lucas Rodrigues Pacheco, policial militar, ratificou, na íntegra, o depoimento do colega de farda, em especial, o local, ponto conhecido pela venda de entorpecentes; avistou os dois no escadão; ao se aproximar, ambos se levantaram; abordados, encontrou drogas com eles, cuja quantidade não se lembra (maconha e cocaína); ambos confessaram a traficância; foi apreendido pena quantidade de dinheiro com um deles (áudio sistema SAJ).

Assim, como se vê, com o término da instrução, ficou comprovado que todo o entorpecente apreendido pertencia ao réu Rodrigo e ao comparsa, o menor Kayk.

O relato das testemunhas de acusação, somadas ao Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Laudo de Constatação Prévia e Exame Químico Toxicológico, tudo aponta no sentido de que a versão apresentada pelos policiais é a verdadeira, eis que encontra simetria com as demais provas dos autos.

Com sua conduta, o réu se enquadra em, pelo menos, um verbo do tipo previsto no artigo 33 da lei especial: trazer consigo.

Destarte, verifica-se que a ação penal procede.

De fato, os depoimentos dos policiais foram claros, serenos e seguros, dando conta da apreensão em poder do acusado, de razoável quantidade de substância

entorpecente, o suficiente a denotar o intuito da traficância.

Também ficou evidente a participação do infante Kayk, cúmplice do acusado na venda das drogas em via pública.

A materialidade está estampada no Boletim de Ocorrência (fls. 02/05), no Auto de Exibição e Apreensão (fl. 10), no Auto de Constatação Prévia (fls. 13/16) e no Exame Químico Toxicológico (fls. 96/98).

Este último demonstra que as substâncias apreendidas realmente eram cocaína e maconha.

Em que pese à insurgência da Defesa, a traficância restou devidamente caracterizada e comprovada.

Como visto, os depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo são coerentes e harmônicos e traduzem a certeza de que o réu, efetivamente, trazia consigo, nas mãos, razoável quantidade de cocaína e no bolso do comparsa a maconha, quando foi flagrado pelos agentes.

Portanto, restou claro que os policiais prenderam o acusado em flagrante em plena conduta típica, apreendendo em seu poder toda a cocaína e maconha encontrada.

Bem sabemos, como já dito acima, que incide nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aquele que é detido com expressiva quantidade de substância tóxica.

No caso concreto, a droga estava sendo trazida, para entrega a consumo de terceiros, pelo acusado em via pública, instante em que foi abordado por policiais, o que configura tráfico e não uso de drogas.

Assim, uma vez que o réu foi surpreendido tendo consigo substância entorpecente, não se pode falar em guarda para consumo próprio, com a consequente desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, mas sim em tráfico ilícito.

Certo é que, a só quantidade de droga, ainda que razoável, não define, por si só, a condição de traficante. Mas no presente caso, verifica-se que o réu foi flagrado trazendo consigo toda a cocaína e o comparsa a maconha, em uma escadaria.

É sabido que se tem reiteradamente decidido que para a caracterização do delito previsto no artigo 33, não se faz necessário seja o infrator colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Tratando-se de crime de mera conduta, ter em depósito, guardar, transportar, trazer consigo, não importa a modalidade, forçoso reconhecer-se à configuração do crime em tela.

Ademais, por importante, mister se faz atentar para a natureza e a quantidade da substância apreendida (11,4g de cocaína e 15g de maconha), o local (nas mãos do indiciado e dentro do bolso do comparsa) e as condições em que se desenvolveu a atividade delituosa (policiais visualizaram o réu e o menor em uma escadaria em atitude suspeita, ocasião em que realizaram a abordagem e localizaram as drogas).

Outrossim, não há que desmerecer os depoimentos dos policiais - ouvidos como testemunhas - tão só pelo fato de serem eles integrantes da Polícia.

Tal significaria preconceito odioso e inaceitável, caracterizando mesmo clara discriminação profissional que não tem qualquer respaldo jurídico.

Observe-se que, a Defesa nada comprovou contra a honradez e honorabilidade dos policiais ouvidos como testemunhas neste processo, nem mesmo que tivessem eles qualquer razão escusa para pretenderem prejudicar o acusado.

Assim, seus depoimentos não de ser prestigiados, em especial porque apresentam contornos de verossimilhança, estão conforme o conjunto das provas e, ademais, como já dito, são coerentes entre si, formando um todo harmônico e lógico.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa - Preliminar de cerceamento de defesa - Inocorrência - Rejeitada - Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas - Acusada surpreendida mantendo em depósito drogas para imediata distribuição - Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência - Validade - Contradições insignificantes e incapazes de ensejar a absolvição - Pena base alterada, mas sem reflexo na pena final - Redutor negado, mercê da expressiva quantidade de drogas apreendidas - Regime mantido em razão da gravidade da conduta - Apelo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1501099-78.2020.8.26.0567; Relator (a): Fernando Torres Garcia; Órgão

Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/02/2021; Data de Registro: 15/02/2021)

APELAÇÃO - Tráfico ilícito de drogas, dano qualificado e resistência em concurso material - Autoria e Materialidade comprovadas - Palavra dos Policiais Militares - Validade - Precedentes - Circunstâncias fáticas que demonstram o comércio ilícito de drogas realizado pelo réu - Laudos periciais corroborando a ocorrência dos delitos de resistência e dano qualificado - Incabível a alegação de insuficiência probatória - Pena - Dosimetria - Pleito de reconhecimento do redutor - Atendimento - Impossibilidade - Circunstâncias do caso concreto que indicam que o acusado se dedicava a atividades criminosas, no caso, ao tráfico habitual de drogas - Penas de todos os delitos fixadas de maneira apropriada - APELO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501890-92.2018.8.26.0510; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Rio Claro - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/02/2021; Data de Registro: 15/02/2021).

Não se pode negar valia aos depoimentos dados pelos policiais nestes autos, pois, repita-se, produzidos de forma segura e extreme de dúvidas.

Como já dito, não há sequer sugestão de que tivessem eles o mínimo interesse em incriminar o acusado injustamente, mormente diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de denúncia caluniosa. Frise-se que, por importante, a conduta do réu atingia diretamente o adolescente Kayk, seu cúmplice no crime, situação essa que configura a majorante prevista no inciso VI, do artigo 40 da lei especial.

O relato do acusado encontra-se isolado no contexto probatório com o qual, aliás, colide frontalmente. O réu não apresentou em juízo qualquer testemunha que pudesse confirmar sua narrativa, sua condição de usuário e compra de muitas porções, ante sua deficiência física (fl. 18).

Por fim, o fato de ter uma única perna e por essa razão quando ia comprar entorpecentes o fazia em grande quantidade, não é suficiente para isentá-lo, já que foi detido no local de compra de drogas e na companhia do menor, ou seja, na via pública (e não dentro de casa).

Ante o exposto, conclui-se que o contexto probatório é harmônico e coerente; robusto o bastante a embasar a expedição de um édito condenatório.

O réu realizou conduta antijurídica que se subsume em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se a condenação e a pena que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art. 65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Cód. Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 2ª ed. Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Prevê o artigo 42 da Lei nº. 11.343/06: O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

O réu não possui antecedentes (fl. 30).

Sua culpabilidade, entendida como índice de reprovabilidade de sua conduta, no caso, é de média intensidade.

Sua personalidade e conduta social não de ser tidos por média intensidade.

Atento, ainda, ao motivo do delito - qual seja, o ânimo de auferir lucro, já que se dispôs a trazer a droga no meio da rua - bem como, atento às circunstâncias e funestas consequências da infração, que degrada a pessoa e compromete o tecido social e, em especial, considerando a quantidade de substâncias entorpecentes que o acusado trazia consigo, com os malefícios de todos conhecidos, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase não há agravantes ou atenuantes a considerar.

Uma vez que a conduta abrangeu o adolescente Kayk (art. 40, VI), aumento a pena anterior em 1/6 (um sexto), chegando-se a pena de 1/6 (um sexto), chegando a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

O acusado faz jus à causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33 da nova lei de entorpecentes, eis que é primário e possui bons antecedentes, devendo sua pena ser reduzida no patamar de 2/3 (dois terços), chegando-se a pena final de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias multa, a qual torno definitiva na ausência de outras modificadoras.

Cada dia multa fica fixado no valor mínimo previsto na lei especial, dada a pouca fortuna do réu, dado que emerge dos autos.

Atento a primariedade do acusado, além da quantidade de pena imposta, fixo o regime aberto para cumprimento de pena.

Anoto que, este posicionamento, neste caso, partiu da necessidade de proporcionar ao réu uma nova oportunidade, pois não adianta somente castigar o indivíduo; retirá-lo do convívio da sociedade e de seus familiares, da possibilidade de conseguir sustentar-se e encarcerá-lo novamente gerará uma revolta; a descrença na justiça será enorme; sua não reinserção na sociedade fará com que acabe praticando novas infrações e, atolando ainda mais o sistema carcerário.

DECISÃO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO e o faço para declarar Rodrigo Rezende Zorzo, qualificado nos autos na fl. 20, incurso no artigo 33, caput, c.c. parágrafo 4º, c.c. artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias multa, cada qual no valor mínimo legal, ante a pouca fortuna do condenado, dado emergente dos autos.

Preenchendo o acusado os requisitos do artigo 43 e seguintes do Código Penal, converto sua pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam, uma prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas a critério do Juízo das Execuções Criminais, mais pagamento de 10 (dez) dias multa.

Neste sentido:

APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Apelo do Ministério Público desprovido - Quantidade de entorpecente apreendida que não pode ser considerada expressiva, razão pela qual a pena-base deve ser mantida no mínimo legal - Ausente prova de que o réu se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa - Cabível o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, com a redução da pena, em sua fração máxima (2/3), nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 - Viável a substituição da reclusiva por duas penas alternativas, consistentes em prestação de serviços comunitários e outra multa - Também deve ser modificado o regime inicial para o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP - Precedentes do C. STJ e do E. STF - APELO DO MP DESPROVIDO - RECURSO DEFENSIVO PROVIDO para reduzir as penas a 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, bem como para modificar o regime para o aberto, substituindo-se a reclusiva por penas restritivas de direitos - Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado. (TJSP; Apelação Criminal 1500317-90.2018.8.26.0551; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de

Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020)

Tráfico de drogas. Conduta de trazer consigo, expor à venda e guardar 46 porções de cocaína. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Depoimentos de policiais militares que efetuaram a prisão. Usuário surpreendido no momento da abordagem que afirmou ter adquirido entorpecente do réu. Validade e suficiência para a procedência da ação penal. Circunstâncias da prisão e modo de acondicionamento indicativos do intuito mercantil. Condenação mantida. PENA. Majorante referente à proximidade de igrejas e estabelecimentos de ensino que não pode ser mantida. Absoluta ausência de indicativos no sentido de que a traficância colocava em risco os seus frequentadores. Redução para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão da pena reclusiva em restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Imposição do regime aberto. Apelo defensivo parcialmente provido para esse fim. (TJSP; Apelação Criminal 0000271-94.2017.8.26.0557; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020)

Nos termos do artigo 63, caput e §1º, da Lei 11.343/2.006, determino, se for o caso, o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Deixo de determinar o lançamento do nome do réu no rol dos culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas armazenadas para contraprova, no prazo máximo de 30 dias, devendo a autoridade policial enviar termo da incineração.

Por fim, deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser ele beneficiário da gratuidade judiciária, vez que assistido pela Defensoria Pública. P . I . C .

São Paulo, 1º de abril de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.